

三、在案证据能排除合理怀疑：允许被告人对案件基础事实提出线索或证据予以反驳

被告人对公诉机关的指控可提出证据或线索予以反驳，如对涉案财产的来源进行说明、提供单项或多项资金交易明细的证据材料，只要被告人提供的证据或证明材料具有客观性、真实性，具有合理的怀疑，即应依据有利于被告人的原则以及排除合理怀疑原则，对其反证予以采纳。与民事诉讼依照优势证据证明标准不同，刑事诉讼要求根据证据链得到的审判结论具有唯一性，不能有其他合理怀疑。审判机关对案件事实进行认定时，不仅要考虑单个证据的证明力，更要结合整个证据链依照逻辑规则进行分析、论证、判断，依靠缜密的法律思维及经验法则对各种可能性进行探求。在辩方确有证据证明涉案账户中钱款系合法收入的情况下，对合法收入的部分应予以剔除。

具体到本案中，本案的争议焦点是公诉机关没有向法庭提交完整的被害人、被告人、涉案金额的明细，指控的诈骗资金数额能否确认。笔者认为，公安机关委托鉴定机构提取到了财务人员电脑中业务员业绩统计表等电子数据，相关业绩统计数额均经过业务员本人核对，能够客观、全面地反映骗取钱款情况。审计机关以该电子数据中业务员业绩统计表为依据，结合其他证据进行了专项司法审计，并根据各被告人的职务、任职时间等，分别认定犯罪数额和违法所得数额等，可作为确定涉案被告人诈骗资金数额的关键证据，此外，本案还综合考虑了被告人供述及辩解、证人证言等言词证据，并结合涉案账户的资金往来明细、交易记录等重要证据予以佐证，同时允许被告人提出反证或反驳，其可对公诉机关及审计报告的指控数额提出异议，如提供线索或证据去论证涉案款项中的某笔或多笔资金不属于诈骗金额，但被告人在庭审质证过程中，并未提出有效的线索或证据材料，故认定杨某某的证据材料足以排除合理怀疑，将被告人诈骗行为实施期间，其银行卡内收取的款项认定为诈骗资金数额，具有正当性和合理性。

编写人：北京市东城区人民法院 石
魏 北京市高级人民法院 王
伟娜

电信网络诈骗中关爱性聊天信息诈骗性质的司法界定

—— 陈某等诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省铜鼓县人民法院(2023)赣0926刑初31号刑事判决书

2. 案由: 诈骗罪

【基本案情】

2022年12月, 陈某发现某境外资金盘赚钱教程, 此教程包含了网络“杀洋盘”的套路及话术, 认为有利可图, 便计划伙同朋友在某县实施网络“杀洋盘”。随后, 陈某购买了USDT(虚拟货币)、“杀洋盘”教程及话术模板, 另购买了电话卡、二手电脑、手机等作案工具。陈某先后邀请被告人张某、彭某、朱某、高某入股, 并招募到谢某、姚某(均另案处理)等十余名业务员从事网络“杀洋盘”工作。陈某将网络“杀洋盘”教程以及话术模板发到内部群聊, 并通过“粉商”(专业引流的人)将境外客户随机引流到业务员社交软件账号, 业务员把自己包装成所分配的手机卡属地的“成功人士”, 按照话术模板使用翻译软件向对方发送聊天信息, 通过嘘寒问暖逐步获取信任, 再谎称是某平台的高级代理, 继续用话术诱导对方充值某平台会员以获得更多的任务或拉新人充值获利。待时机成熟, 陈某便关闭平台将境外

61148条。

客户在平台充值的钱款项据为 己有。截至案发，该诈骗团伙共发送包含关
爱性聊天信息在内的诈骗信息共计

61148条。

【案件焦点】

行为人在进行电信网络诈骗活动中依照话务本虚构身份、事实，搭讪被害人建立联系，其中通过即时聊天软件发送的嘘寒问暖等关爱性聊天信息能否认定为诈骗信息。

【法院裁判要旨】

江西省铜鼓县人民法院经审理认为：被告人陈某、张某、彭某、朱某、高某合资设立专门从事诈骗活动的办公场所，以业务员身份进行诈骗活动时，均按照话术模板以“成功人士”使用翻译软件进行“杀洋盘”。上述人员向客户发送关爱性聊天信息的目的不在于交友而在于骗取“目标客户”的信任，然后在此基础上诱使客户到某平台充值或拉新人充值获利。此类嘘寒问暖等关爱性聊天信息，虽不涉及具体的骗取财产内容，但是被告人以诈骗为目的而采用的手段，欺骗、诱导性强，应认定为诈骗信息。因此，上述被告人以非法占有为目的，利用电信网络技术虚构事实，对不特定多数人发送了61148条诈骗信息，属于《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“其他特别严重情节”，其行为构成诈骗罪（未遂）。江西省铜鼓县人民法院根据陈某的自首情节，张某、彭某、朱某、高某的从犯情节，作出如下判决：

一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；

二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；

三、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；

四、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；

五、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；

六、扣押在案的优盘二个，予以没收，上缴国库；

七、扣押在案的作案工具手机五十五部、作案电脑二十一台、话务本十二本，予以没收，由扣押机关依法处置。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

电信诈骗信息的认定将直接影响到案件定性、量刑问题，对关爱性聊天信息性质的准确界定至关重要。关爱性聊天信息是否属于诈骗信息应从电信网络诈骗犯罪活动整体性角度进行分析、判断，不能简单将关爱性聊天信息单独拎出来进行分析、判断。为准确界定关爱性聊天信息性质，可以围绕关爱性聊天信息产生的时间、形式以及内容三个要点进行分析判断。

一、在时间上，关爱性聊天信息形成于电信网络诈骗活动预备阶段，不具备正常聊天属性

一般情况下，正常的嘘寒问暖等关爱性聊天信息是出于友情关怀等心理因素或者伴随聊天情境即时产生的，具有即时性、关怀性。而在电信网络诈骗活动中，行为人向被害人发送的嘘寒问暖等关爱性聊天信息并非即时产生的，而是在实施电信诈骗活动之初就被设计出来，并根据被害人反应随时作出调整，具有很强的针对性、目的性和欺骗性，不具备正常聊天属性。正如，本案中，陈某等人向不特定群体发送的嘘寒问暖等关爱性聊天信息在实施诈骗活动之初就设计在诈骗话术模板中，并非在沟通交流中即时产生的，陈某等人发送这些信息目的不在于聊天而在于骗取信任。故，从聊天信息形成时间上来看，关爱性电信诈骗信息与正常的关爱性聊天信息还是有一定区别的。

二、在形式上，关爱性聊天信息属于电信网络诈骗话术中诈骗信息的组成部分

当前电信网络诈骗活动主要是利用诈骗话术模板实施的，行为人按照话术模板先向被害人发送关爱性聊天信息，后骗取钱款，整个过程信息往来频繁。从整体来看，电信诈骗话术模板就是一个系统、完善的诈骗信息，其中包含了嘘寒问暖等关爱性聊天信息、骗取钱财铺垫信息、诱骗处分财产信息三种信息类别，它们之间是一种相互独立又循序渐进的关系，各自在不同时间节点承担着不同的任务。例如，在本案中，陈某等人事先通过诈骗话术模板向不特定群体发送嘘寒问暖等关爱性聊天信息意图获取“目标客户”的信任，获取信任后

再向“目标客户”发送“谎称是某平台高级代理”等诱骗处分财产的铺垫信息，铺垫完成后再发送要求“目标客户”充值会员等要求处分财产信息。故，从形式上看，关爱性聊天信息同具有诱骗处分财产内容的信息一样都是电信诈骗话术模板中独立的组成部分，都是为了骗取钱财而实施的虚构事实。

三、在内容上，关爱性聊天信息对被害人财产转移具有意思支配力

电信网络诈骗罪属于典型的交往沟通型犯罪，其本质在于行为人与被害人交往沟通中，对被害人在理性选择财产转移条件上进行了意思支配，其中财产转移条件由财产转移的基础和合理缘由组成。远距离、非接触式的电信诈骗获得“成功”关键是博取受害者信任，缺乏信任这个关键的因素诈骗将无法得逞。电信诈骗活动中，行为人提前设计、伪造关爱性聊天信息与被害人进行沟通互动，意在通过伪造信息对交往沟通过程进行了单方面操纵，从而获得被害人的信任，进而建立信任关系来麻痹被害人防范电信诈骗意识，使其丧失反诈思考能力，进而对被害人财产转移进行意思支配。此外，一旦行为人通过关爱性信息聊天获得被害人的信任，对双方交往沟通进行意思支配，被害人财产就处于一种紧迫的危险状态，后续包含处分财产内容的信息就只起到一个顺水推舟的作用，被害人成功交出财物不由行为人发出的“具有财物处分内容”信息的真实性或诱惑性所决定，而由行为人发送的关爱性聊天信息致使被害人受到误导，对行为人深信不疑，形成诈骗罪上的信赖要件所决定的。故，在电信网络诈骗活动中对整个诈骗活动起控制作用的是关爱性聊天信息，其危害性更大，应认定为诈骗信息。

编写人：江西省铜鼓县人民法院 袁永胜 吴丽红

电信诈骗中非法经营、 非法获取公民个人信息行为的定性及罪数认定

——代某等诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河北省石家庄市中级人民法院(2024)冀01刑终157号刑事判决书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

被告人代某为牟取非法利益，先后于2016年8月、2019年3月成立甲网络科技有限公司和乙网络科技有限公司，被告人代某为上述两个公司实际控制人，两公司不具备证券投资咨询资质。2016年8月至2020年12月被告人代某陆续招募被告人熊某等19人、2021年2月至3月陆续招募被告人毛某等8人为业务员，27人均无股票相关知识。代某编造固定的话术单，指使其他被告人冒充知名证券公司工作人员，以拨打电话、微信添加客户等方式针对不特定的被害人推荐股票，并以虚构的姓名和“公司有专业的股票分析师、有内幕消息、有实力拉升股价、稳赚不亏”等特定话术骗取被害人信任，向被害人收取提成、服务费等。经统计，2020年6月至2021年4月，已落实的被害人转账金额共计979984.33元(含服务费435300元)。公安民警在现场查获伪造的海通证券投资服务合同6份，涉及核心服务费(咨询费)78400元。

被告人代某为实施诈骗犯罪，其通过股票交流群等非法购买公民个人信息5万余条及1500余万个电话号码。

代某等因形迹可疑被司法机关盘问时如实供述了自己的犯罪事实。到案后，代某家属代其退赔违法所得9万元。

【案件焦点】

1. 代某等构成诈骗罪还是非法经营罪；2. 代某非法购买公民个人信息实施诈骗是否应数罪并罚。

【法院裁判要旨】

河北省石家庄市桥西区人民法院经审理认为：被告人代某等未经有关部门核准，为证券交易活动提供服务，其行为属于非法经营。但代某等人在非法经营过程中又虚构事实、隐瞒真相，使被害人陷入错误认识而交付提成、服务费等费用，其行为属于诈骗。上述过程中，非法经营系被告人代某等人为实施诈骗所采取的部分手段，按照择一重处原则，代某等被告人的行为应构成诈骗罪。代某通过购买等方式非法获取公民个人信息，用于实施违法犯罪活动，情节特别严重。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。被告人代某同时构成诈骗罪及侵犯公民个人信息罪，应数罪并罚。代某等在诈骗罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被司法机关盘问时就如实供述自己的犯罪事实，以自首论，可从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：

一、被告人代某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20万元；被告人代某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币25万元；

第二至第二十八、其他27名被告人犯诈骗罪，判处四年至两年四个月有期徒刑，并处罚金人民币8万元至5000元不等，并根据犯罪情节或适用缓刑。

二十九、公安机关扣押在案的电脑、记账本、手机等物品，由扣押机关依法没收；

三十、继续追缴各被告人违法所得，并发还被害人。

一审宣判后，代某以不应认定为诈骗罪而应构成非法经营罪，侵犯公民个人信息罪与非法经营罪系牵连犯应从一重罪处罚为由，提出上诉。

河北省石家庄市中级人民法院经审理认为：原审被告人代某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。代某在实施诈骗行为中，违反国家有关规定，购买公民信息，情节特别严重，构成侵犯公民信息罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，应数罪并罚。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，对辩护意见的驳辩理据充足，论理透彻。原审被告人代某的上诉意见，不予支持。但原审法院对被告人代某的量刑不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项、第二项，第二百四十四条之规定，判决：

一、维持河北省石家庄市桥西区人民法院(2023)冀0104刑初429号刑事判决第二项至第三十项；

二、撤销河北省石家庄市桥西区人民法院(2023)冀0104刑初429号刑事判决第一项对代某的量刑；

三、上诉人(原审被告人)代某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币20万元；被告人代某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币25万元。

【法官后语】

本案系诈骗犯罪活动中，非法经营行为和非法购买公民个人信息行为的定性及罪数认定。主要争议焦点为：一是代某等构成诈骗罪还是非法经营罪；二是代某非法购买公民个人信息实施诈骗犯罪是否应数罪并罚。

